

1500405-60.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... réus se dedicavam à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes. Nesse ponto, anoto que Kauã afirmou que perpetrava o tráfico de drogas há cerca de cinco meses. Em relação a Luiz Rodrigo, os documentos de fls. 283/310 e sua condenação nos autos nº 1500164-08.2021 (fls. 276/277), ainda que transitada em julgado após os fatos ora analisados, demonstram que há muito ele se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500405-60.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072398/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23631008 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2072398 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÃ HENRIQUE SOUZA AMARAL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

KAUÃ HENRIQUE SOUZA AMARAL e LUIZ RODRIGO MELO SOUZA RAYMUNDO estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

Notificados (fls. 224 e 225), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 216/221 e 232/235).

A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 236/237) e os acusados foram citados (fls. 270 e 272).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus (fls. 311/312).

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, nos termos da denúncia.

A defesa de Kauã pleiteou a fixação da pena mínima legalmente cominada, com reconhecimento da atenuante de confissão e aplicação do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa de Luiz Rodrigo pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela aplicação da pena mínima com reconhecimento das benesses legais.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/12), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotografias (fls. 59/60), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 188/192) e pela prova oral.

Interrogado em juízo, Kauã admitiu a propriedade das drogas, afirmando que as comprara cerca de três meses antes dos fatos e que elas se destinavam à venda, pois perpetrava o comércio ilícito há aproximadamente cinco meses. Declarou que estava levando o corréu para comprar medicamento para a filha dele e tinham parado em um posto para abastecer quando viu a viatura e dispensou os entorpecentes, abrindo a porta do passageiro. Negou que tivessem sido encontradas drogas em sua posse. Deixou Luiz Rodrigo dirigir seu carro porque não tem habilitação, embora não saiba se ele é habilitado. Atualmente está preso por tráfico.

Luiz Rodrigo negou a acusação e disse que era perseguido pelos policiais. Relatou pegou uma carona com Kauã para a farmácia e, embora não tenha habilitação, dirigia o carro dele. Quando receberam ordem de parada, Kauã lhe contou que tinha drogas no porta-luvas do automóvel e, ao serem abordados, o coacusado informou tal fato aos policiais e assumiu a propriedade dos entorpecentes. Após o encontro das drogas, os policiais ficaram andando pelas proximidades, o agrediram e pressionaram Kauã para incriminá-lo.

O policial militar José Vinícius relatou que estava em patrulhamento quando avistou o veículo Uno em um posto e percebeu que seus ocupantes demonstraram nervosismo ao verem a viatura. Retornou e deu ordem de parada ao condutor do automóvel, que estava em marcha pela via pública, mediante sinais sonoros e luminosos. A ordem não foi imediatamente obedecida e, como o Uno não tinha insulfilme nos vidros e o farol alto da viatura estava ligado, visualizou quando o motorista arremessou um objeto pela janela do passageiro e, depois disso, entrou em uma rua transversal e daí parou o carro. Realizada a abordagem, localizou dinheiro com condutor Luiz Rodrigo e 6 porções de crack com o passageiro Kauã. Seu colega retornou ao local em que o objeto fora dispensado e encontrou uma sacola com uma porção bruta de maconha e 51 porções de crack embaladas de forma semelhante àquelas que estavam com Kauã. Luiz Rodrigo afirmou que não tinha jogado nada pela janela do carro e Kauã disse que as drogas que estavam com ele eram para consumo próprio. Não conhecia Kauã antes dessa abordagem, todavia o prendeu alguns meses depois por tráfico. Conhecia Luiz Rodrigo somente por nome, pois ele fora indicado como sendo o proprietário de entorpecentes encontrados com terceiro em abordagem concretizada uma semana antes.

No mesmo sentido, em linhas gerais, as declarações do policial militar Marcus, que asseverou ter visto o condutor do Uno arremessando algo pela janela do passageiro e, ao retornar ao local, localizou a sacola do lado direito da via e próximo ao meio fio contendo uma porção bruta de maconha e 51 pedras de crack.

A genitora de Luiz Rodrigo, Marcluce, nada esclareceu sobre o delito e informou ter

ciência de que seu filho saíra de casa na noite dos fatos para comprar remédio para a filha dele.

Pois bem.

Kauã confessou o tráfico e tentou afastar a responsabilização do corréu, mas, pelo que se viu, ele e Luiz Rodrigo apresentaram versões contraditórias sobre detalhes da abordagem policial, que, de resto, foram rechaçadas pelos relatos dos policiais.

Kauã aduziu que transportava somente os entorpecentes armazenados na sacola, por ele mesmo dispensada. Buscando desqualificar os depoimentos das testemunhas quanto à visualização do arremesso, ele afirmou que o veículo tinha as janelas levantadas e que não as abaixou, pois chovia muito na ocasião. Todavia, ao ser questionado como se desfizera dos entorpecentes, timidamente respondeu ter aberto a porta. De outro lado, Luiz Rodrigo negou até mesmo a dispensa confirmada por Kauã e disse que as drogas estavam no porta-luvas do carro.

Nenhum deles apresentou explicação plausível para Luiz Rodrigo estar conduzindo o automóvel supostamente pertencente a um parente de Kauã, vez que também não possuía CNH.

Em contraposição, os policiais militares foram uníssonos e coerentes em suas oitivas quanto às circunstâncias da diligência e explicitaram ter visualizado o motorista, posteriormente identificado como Luiz Rodrigo, arremessando um objeto que depois descobriram ser uma sacola contendo entorpecentes.

A finalidade de entrega a terceiro restou comprovada pela confissão de Kauã e pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder dos acusados. Não se olvide, ainda, o comprovado envolvimento anterior de Luiz Rodrigo com o comércio espúrio (fls. 276/277 e 283/310).

Nesse contexto, suficientemente comprovada a prática, pelos acusados, do crime narrado da denúncia, de rigor a procedência da ação penal.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, observo que as penas-base comportam majoração, em virtude da alta potencialidade lesiva de parte dos entorpecentes apreendidos – crack – substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo suas penas-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para cada um.

Presente a confissão para Kauã e, para ambos, a atenuante da menoridade e a agravante descrita no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”). Assim, mantenho a pena no patamar anterior.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da comprovação de que os réus se dedicavam à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes. Nesse ponto, anoto que Kauã afirmou que perpetrava o tráfico de drogas há cerca de cinco meses. Em relação a Luiz Rodrigo,

os documentos de fls. 283/310 e sua condenação nos autos nº 1500164-08.2021 (fls. 276/277), ainda que transitada em julgado após os fatos ora analisados, demonstram que há muito ele se dedicava ao comércio espúrio.

Considerando os motivos esposados na primeira e na terceira fases da dosimetria e o disposto na Lei nº 8.072/90, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena corporal por ambos.

Arbitro o valor do dia-multa no patamar mínimo, pois ausentes elementos que demonstrem serem os réus capazes de arcar com valor maior.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente

diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c. c. art. 29, CP, os réus KAUÃ HENRIQUE SOUZA AMARAL e LUIZ RODRIGO MELO SOUZA RAYMUNDO à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

O réu Luiz Rodrigo não poderá apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar (fls. 93/94), notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Faculto a Kauã o apelo em liberdade, vez que assim permaneceu durante a instrução processual.

Por fim, decreto o perdimento dos objetos e valores apreendidos, inclusive do veículo FIAT-Uno descrito às fls. 58 e 159, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA